

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1273/2563

พนักงานอัยการจังหวัดกันทรลักษ์ โจทก์
เด็กชาย อ. โดยนาง ค. ผู้แทนโดยชอบ
ธรรม กับพวก

โจทก์ร่วม

นาย ก. จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (18), มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม), มาตรา 279 วรรคสี่, มาตรา 279 วรรคห้า

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกามี พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 ออกใช้บังคับ โดยมาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา 277 และให้ใช้ความใหม่แทน และมาตรา 3 ให้เพิ่มความในมาตรา 1 แห่ง ป.อ. "(18) "กระทำชำเรา" หมายความว่า กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้ อวัยวะเพศของผู้กระทำล้วงล้าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น" กรณี เป็นเรื่องกฎหมายที่บัญญัติในภายหลังกำหนดองค์ประกอบความผิดฐานกระทำชำเรา ว่า จะต้องเป็นการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล้วงล้าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่อง ปากของผู้ถูกระทำจึงจะเข้าเกณฑ์เป็นความผิด

จำเลยใช้มือจับอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 1 สอดใส่เข้าไปในช่องทวารหนัก ของจำเลย และใช้ปากของจำเลยอมอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 1 โดยไม่ได้ใช้ อวัยวะเพศของจำเลยล้วงล้าอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของโจทก์ร่วมที่ 1 การกระทำได้กล่าวจึงไม่เป็นการกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีตาม ป.อ. มาตรา 227 วรรคสาม อีกต่อไป และแม้การกระทำของจำเลยดังกล่าวจะไม่ได้เข้าไป

ในอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 1 แต่ก็เป็นกรกระทำที่ไม่สมควรทางเพศอันเป็นการ
ล่วงเกินโจทก์ร่วมที่ 1 แล้ว จึงเป็นการล่วงล้ำอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 1 เป็น
ความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยการล่วงล้ำตาม ป.อ.
มาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 277,
279, 283 ทวิ, 285/1, 317

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณาเด็กชาย อ. ผู้เสียหายที่ 1 โดยนาง ค. มารดาผู้แทนโดยชอบ
ธรรม และนาง ค. ผู้เสียหายที่ 2 ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต
โดยให้เรียกผู้เสียหายที่ 1 ว่าโจทก์ร่วมที่ 1 เรียกผู้เสียหายที่ 2 ว่าโจทก์ร่วมที่ 2

โจทก์ร่วมทั้งสองยื่นคำร้องขอให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมที่
1 เป็นเงิน 500,000 บาท แก่โจทก์ร่วมที่ 2 เป็นเงิน 504,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันกระทำละเมิดเป็นต้นไป
จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ร่วมทั้งสอง

จำเลยให้การในคดีส่วนแพ่งว่า จำเลยไม่ได้กระทำความผิดตามฟ้อง จึงไม่ต้อง
รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ร่วมทั้งสอง ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
277 วรรคสาม (เดิม), 279 วรรคแรก (เดิม), 283 ทวิ วรรคสอง (เดิม), 317 วรรค

สาม (เดิม) การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อการอนาจาร จำคุกกระทงละ 6 ปี รวม 2 กระทง เป็นจำคุก 12 ปี ฐานพาเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร ฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน และฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุกกระทงละ 8 ปี รวม 2 กระทง เป็นจำคุก 16 ปี รวมจำคุก 28 ปี กับให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ร่วมที่ 1 เป็นเงิน 100,000 บาท แก่โจทก์ร่วมที่ 2 เป็นเงิน 55,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ 30 กันยายน 2559 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ร่วมทั้งสอง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาแก้เป็นว่า ฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อการอนาจาร จำคุกกระทงละ 5 ปี รวม 2 กระทง เป็นจำคุก 10 ปี ฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีซึ่งมิใช่ภริยาหรือสามีของตน จำคุกกระทงละ 7 ปี รวม 2 กระทง เป็นจำคุก 14 ปี รวมทุกกระทงความผิดแล้ว จำคุก 24 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้โจทก์มี โจทก์ร่วมที่ 1 เด็กชาย ว. และเด็กชาย ร. เป็นประจักษ์พยานเรื่องที่จำเลยนัดโจทก์ร่วมที่ 1 ไปพบที่บ้านและไปที่ห้วยชะยุ้ง เด็กชาย ร. เห็นจำเลยกับโจทก์ร่วมที่ 1 แก้วผ้า จำเลยเอาอวัยวะเพศใส่ด้านหลังโจทก์ร่วมที่ 1 เหตุเกิดที่บ้านจำเลย โดยเห็นในลักษณะแอบดู จำเลยยังเคยลวนลามจับอวัยวะเพศของพยานในบ้านจำเลยและที่โรงเรียน พยานโจทก์ดังกล่าวเบิกความสอดคล้องกลมกลืนกัน ไม่มีเหตุให้น่าระแวงสงสัย ส่วนที่ปรากฏในใบนำส่งผู้บาดเจ็บ และผลการตรวจชั้นสูตรบาดแผลของโจทก์ร่วมที่ 1 ที่ระบุว่า อวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 1 ปกติ ไม่พบรอยฉีกขาด ทวารหนัก ปกติ ไม่พบรอยฉีกขาด ก็ปรากฏจากคำโจทก์ร่วมที่ 1 ว่า ตอนแรกจำเลยจะกระทำเวจมรรคกับโจทก์ร่วมที่ 1 แต่อวัยวะเพศของจำเลยใหญ่เกินไป จำเลยจึงให้โจทก์ร่วมที่ 1 กระทำกับจำเลยแทน ผลการตรวจชั้นสูตรดังกล่าวจึงไม่เป็นพิรุณแต่อย่างใด ที่ได้ความจากนาง อ. พยานโจทก์ซึ่งเป็นครูประจำชั้นของโจทก์ร่วมที่ 1 ว่า โจทก์ร่วมที่ 1 ไปเปิดอวัยวะเพศให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ดู พยานจึงตามโจทก์ร่วมที่ 1 มาสอบถาม โจทก์ร่วมที่ 1 ให้ถ้อยคำเรื่องที่เด็กชาย ว. ไปมีเพศสัมพันธ์กับนาย ป. และตนเองกับจำเลย เด็กชาย ว. และ นาย ป. ไปเล่นน้ำกันที่ห้วยชะยุ้ง นาง จ. พยานโจทก์ซึ่งเป็นครูโรงเรียนของโจทก์ร่วมที่ 1 เบิกความว่า โจทก์ร่วมที่ 1 เล่าให้ฟังว่า จำเลยให้โจทก์ร่วมที่ 1 ถอดเสื้อผ้าแล้วนอนลง จำเลยพยายามเอาอวัยวะเพศสอดใส่ด้านหลังแต่เข้าไปไม่ได้ นาง จ. พยานโจทก์เบิกความว่า โจทก์ร่วมที่ 1 ไปที่ป่ามันสำปะหลังกับจำเลย จำเลยใช้มือทำอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 1 ส่วนเด็กชาย ว. กับนาย ป. ไปทำที่เถียงนาจนสิ้น หากไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นจริง มีบุคคล สถานที่หลายสิ่งเข้ามาเกี่ยวข้องก็ยากที่จะเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมา คำพยานโจทก์ดังกล่าวแม้จะเป็นพยานบอกเล่า แต่หากพิจารณาถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและความปรากฏขึ้นมาจากปากคำเด็กนักเรียนชั้นประถมที่ให้ถ้อยคำต่อคณะครูตามสภาพ ลักษณะ และข้อเท็จจริงแวดล้อมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น น่าเชื่อว่าจะพิสูจน์ความจริงได้ ศาลย่อมมีสิทธิรับฟังคำพยานดังกล่าวได้ตามประมวล

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 226/3 วรรคสอง (1) ที่จำเลยฎีกาว่า โจทก์
ร่วมที่ 1 เด็กชาย ว. และเด็กชาย ร. ไม่เคยไปบ้านจำเลย จำเลยไม่เคยพาโจทก์ร่วม
ที่ 1 ไปห้วยชะยุ้ง ไม่อาจจับฟังได้ ที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค 3 วินิจฉัยมาว่า
จำเลยกระทำการล้วงละเมิดทางเพศโจทก์ร่วมที่ 1 พรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไป
เสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง เพื่อการอนาจาร นั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของ
จำเลยฟังไม่ขึ้น

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกามีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
อาญา (ฉบับที่ 27) พ.ศ.2562 ออกใช้บังคับ โดยมาตรา 5 ให้ยกเลิกความในมาตรา
277 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และให้ใช้ความใหม่แทน และมาตรา 3 ให้เพิ่ม
ความในมาตรา 1 แห่งประมวลกฎหมายอาญา "(18) "กระทำชำเรา" หมายความว่า
กระทำเพื่อสนองความใคร่ของผู้กระทำ โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระทำล้วงล้ำ
อวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อื่น" กรณีเป็นเรื่องกฎหมายที่บัญญัติใน
ภายหลังกำหนดองค์ประกอบความผิดฐานกระทำชำเราว่า จะต้องเป็นการใช้อวัยวะ
เพศของผู้กระทำล้วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้ถูกกระทำจึงจะเข้า
เกณฑ์เป็นความผิด อันเป็นการปรับปรุงนิยามคำว่า "กระทำชำเรา" ให้ชัดเจนและ
สอดคล้องกับลักษณะการกระทำชำเราทางธรรมชาติ ดังนั้น เมื่อคดีได้ความว่า จำเลย
ใช้มือจับอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 1 สอดใส่เข้าไปในช่องทวารหนักของจำเลย
และใช้ปากของจำเลยอมอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 1 โดยไม่ได้ใช้อวัยวะเพศของ
จำเลยล้วงล้ำอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของโจทก์ร่วมที่ 1 การกระทำความ
กล่าวจึงไม่เป็นการกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 277 วรรคสาม อีกต่อไป ปัญหาต้องวินิจฉัยต่อไปว่า การกระทำความ
กล่าวเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคแรก (เดิม) หรือเป็นความผิดฐานกระทำอนาจารแก่
เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยการล้วงล้ำตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279

วรรคสี่และวรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) เห็นว่า แม้การกระทำของจำเลยดังกล่าวจะไม่ได้เข้าไปในอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 1 ก็ตาม แต่ก็เป็นกรกระทำที่ไม่สมควรทางเพศอันเป็นการล่วงเกินโจทก์ร่วมที่ 1 แล้ว จึงเป็นการล่วงล้ำอวัยวะเพศของโจทก์ร่วมที่ 1 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) แต่ความผิดฐานกระทำอนาจารเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีโดยการล่วงล้ำตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) มีระวางโทษจำคุกตั้งแต่เจ็ดปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท หรือจำคุกตลอดชีวิตเท่ากันกับความผิดฐานกระทำชำเราเด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปีตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) ระวางโทษตามกฎหมายที่แก้ไขใหม่ไม่เป็นคุณศาลต้องพิจารณาลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในขณะที่จำเลยกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 วรรคหนึ่ง

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 279 วรรคห้า (ที่แก้ไขใหม่) โดยให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคสาม (เดิม) จำคุกกระหนงละ 7 ปี รวม 2 กระหนง จำคุก 14 ปี รวมโทษฐานพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อกอนาจารตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 แล้ว เป็นจำคุก 24 ปี นอกจากที่แก้ให้ เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3

(ประทีป อ้าววิจิตรกุล-ปกรณ วรสาโรจน์-เอกศักดิ์ ยันตรปกรณ)

ศาลจังหวัดกันทรลักษ์ - นางสาวสุรัสวดี เจียมสุวรรณ

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 - นายสมเจตน์ สุรินทร์ศักดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ